

1518516-57.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518516-57.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518516-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2207004/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 19362253 - 63º D.P. VILA JACUI, 3917/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2207004 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

Emerson Joaquim da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Emerson Joaquim da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado (fls. 97/99) e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 298, inciso III, e 306, caput e §1º, incisos I e II, da Lei 9.503/97, porque, de acordo com a denúncia, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 8h30, na rua Vilanova de Santa Cruz, altura do n. 350, Jardim Matarazzo, neste município, teria conduzido o veículo Renault, modelo Sandero EXP 1.0, 16V, ano 2010/2011, cor vermelha, placa ERQ 5895/São Paulo-SP, sem ser habilitado e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fl. 104).

Ofertada defesa prévia (fls. 126/129), não sendo caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado nas fls. 130/131.

Em audiência, o réu foi declarado revel e foram ouvidas as testemunhas Alex e Gustavo.

Em alegações finais, o MP requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa, a seu turno, não contestou a realidade dos fatos, tendo em vista a flagrância do delito. Consignou, contudo, que o réu não foi advertido quanto ao direito ao silêncio, no momento da abordagem policial, ocasionado contaminação da prova até o encarceramento, mormente quanto à voluntariedade da submissão ao

etilômetro. No mais, sustentou a carência de provas em desfavor do réu, já que não realizado o exame de constatação de embriaguez pelos agentes do Estado. Diante das questões processuais, pugnou pela aplicação do in dubio pro reo, de modo a resultar na absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, suscitando a inobservância das garantias constitucionais na fase pré-processual. Em caso de condenação, requereu o afastamento da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal, em razão da situação de calamidade pública advinda da pandemia ocasionada pela COVID-19, e o reconhecimento da detração da pena, uma vez que o acusado permaneceu encarcerado por 99 (noventa e nove) dias.

Alternativamente, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. Fundamento nos seguintes termos.

O réu não compareceu para ser interrogado, optando pela revelia.

A testemunha Alex declarou que estava em patrulhamento, quando viu o carro conduzido pelo acusado cruzando o canteiro central e entrando na contramão. Foram em seu encalço. Havia outras pessoas no carro e o réu o conduzia. O acusado submeteu-se ao etilômetro. Ele não era habilitado. Apresentava sinais de embriaguez, como vermelhidão nos olhos, fala confusa, odor etílico e tombava de um lado para outro.

A testemunha Gustavo desenvolveu idêntico relato. Disse que o acusado passou pelo canteiro central e entrou na via pela contramão e desceu totalmente transtornado, com confusão mental, não sabendo onde estava, de onde vinha, nome completo e, feito o bafômetro, foi constatada concentração de álcool acima do limite legal. Apresentava sinais de embriaguez como fala desconexa, odor etílico e olhos avermelhados. Não se recordou acerca da existência de habilitação.

Nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 12.760 de 2012, tem-se: "Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:"

O parágrafo primeiro do mencionado artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro esclarece que as condutas previstas em seu caput serão constatadas por i) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (conforme redação do inciso I) ou ii) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (nos termos de seu inciso II).

No presente caso, foi realizado teste de etilômetro (artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, segunda parte), apontando concentração de álcool de "0,36mg/l", concentração superior à legalmente permitida de 6 decigramas de álcool por litro de ar expelido, o que prova a ocorrência da conduta descrita no caput do crime denunciado.

Nesse sentido, nos termos do já mencionado inciso I do parágrafo primeiro do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, presente o elemento do tipo necessário à configuração do delito, sendo dispensável, portanto, o exame de constatação de embriaguez como argumentou a defesa.

Não suficiente, a prova oral produzida apontou a existência de sinais indicativos de embriaguez do acusado. Ambos os policiais relataram que o réu tinha olhos vermelhos, fala desconexa e pastosa, odor etílico e desequilíbrio nas funções motoras.

Diante disso, as provas orais e pericial foram uníssonas quanto à embriaguez do réu quando da ocorrência descrita na inicial acusatória, satisfazendo o ônus da prova quanto a todos os elementos do tipo penal, não sendo cabível o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, como pretende a defesa, tendo em vista a certeza da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Finalmente, o fato de que o réu conduziu veículo automotor com alteração psicomotora pela influência de álcool, por si só, configura risco potencial, já suficiente ao aperfeiçoamento do tipo, restando impossibilitada, conforme já explicitado, a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, no

momento da abordagem policial, resultando em "contaminação da prova" até o "encarceramento", não se vê pertinência no argumento.

Não há mínimo indício de que tenham sido subtraídos os direitos do acusado no momento da flagrância, até porque o requerido não cuidou de vir a juízo dar sua versão dos acontecimentos. Ao revés, consta da fl. 01 que a advertência quanto ao direito ao silêncio foi feita no momento da apreensão.

Mas mesmo que o contrário fosse verdadeiro, o que se diz por argumento, e mesmo que o teste etilográfico não houvesse, a prova oral colhida em juízo seria suficiente para demonstrar o elemento típico. Portanto, se a advertência quanto ao silêncio não foi firmada, tal fato não trouxe prejuízo ao acusado, já que a prova foi feita também por meio diverso e independente.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a falta de advertência quanto ao direito ao silêncio gera nulidade relativa, logo, reclama prova do prejuízo, o que, aqui, não existiu. Senão vejamos:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. "CONFISSÃO" EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

7. Nos termos do art. 186, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 5º, LXIII, da Constituição, o alerta sobre o direito ao silêncio é garantido ao preso e ao acusado de uma prática delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração do prejuízo por quem o alega.

8. No caso em análise, o recorrente não logrou demonstrar o prejuízo suportado em seu direito de ampla defesa ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de permanecer calado, quando da abordagem policial. É que, como consignado no acórdão recorrido, após a prisão, foi devidamente informado acerca de seus direitos constitucionalmente garantidos, conforme comprova o termo de interrogatório indiciário de fl. 07 (e-STJ fl. 409). Ressalte-se, ainda, que as declarações prestadas aos policiais no momento da prisão em flagrante serviram apenas como mais um elemento, dentro do conjunto probatório constante dos autos.

9. Agravo regimental não provido." (STJ – AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Não se ignora a existência do RE 1.177.984, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal julga a questão levantada pela defesa, cuja repercussão geral, inclusive, já foi reconhecida em votação unânime realizada no plenário virtual. Ocorre que ainda não houve julgamento do impasse, encontrando-se o mencionado recurso concluso ao relator desde 16 de dezembro de 2021, motivo pelo qual deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não prospera a tese de carência de provas em desfavor do acusado, diante da ausência do exame de constatação de embriaguez, uma vez que realizado o etilômetro, apontando concentração de álcool de "0,36mg/l", superior à legalmente permitida, suficiente, por conseguinte, à subsunção da conduta ao artigo 306, § 1º, I, segunda parte, do Código de Trânsito Brasileiro, consoante já aventado. Por todo exposto, não prospera a tese de inobservância das garantias em fase pré-processual.

No que toca à agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal, em razão da situação de calamidade pública advinda da pandemia ocasionada pela COVID-19, com razão a defesa, visto que não se prevaleceu o acusado das fragilidades ensejadas pela pandemia, a fim de cometer o crime em julgamento, não se observando, destarte, maior gravidade do injusto e, via de consequência, agravamento do desvalor da ação

apto a majorar a pena na segunda fase da dosimetria.

Por derradeiro, o documento de fl. 01 comprova que o réu não era habilitado para conduzir veículo automotor na data dos fatos, o que torna imperiosa a aplicação da agravante prevista no parágrafo primeiro do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Note-se que o requerido não fez prova de que era habilitado. Ante o exposto, forçosa a condenação do réu.

Passa-se ao cálculo da pena.

Analisando-se os antecedentes do acusado, observa-se que o acusado já ostenta três condenações criminais, o que impede a fixação da pena base no mínimo legal (fls. 29 a 33, 37 a 51 e 52 a 55).

Trata-se dos processos n. 0000102-62.2006.8.26.0050, n. 0055078-43.2011.8.26.0050 e n. 0073986-32.2003.8.26.0050, oriundos, respectivamente, da 27ª Vara Criminal, 14ª Vara Criminal e 27ª Vara Criminal, todas do Foro Central Criminal (fls. 52 a 55), pelos quais o acusado já cumpriu as penas. Tratando-se de penas extintas há mais de cinco anos antes da data dos fatos aqui narrados, não se prestam a fundar reincidência, sendo considerados, no entanto, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593818, com repercussão geral, firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, como maus antecedentes. Confira-se:

"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Deste modo, a conclusão da análise dos antecedentes do réu é que se trata de indivíduo que ostenta três maus antecedentes. Cada qual destes fatores fomentará o aumento de um sexto da pena.

Assim, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de três circunstâncias judiciais negativas, elevo a pena em sua metade, resultando em 1 (um) ano de detenção, 15 (quinze) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente, contudo, a agravante do artigo 298, III, do CTB, eis que provado que o réu não possuía habilitação para dirigir à época dos fatos, razão pela qual majoro a pena em um sexto, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, 17 (dezesete) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase do procedimento de individualização da sanção, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torna-se definitiva a pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, 17 (dezesete) dias-multa e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal, visto que presentes três circunstâncias judiciais negativas.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, pelas mesmas razões, o que justifica a fixação de um regime de pena intermediário para efetiva prevenção e reparação do crime, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" c.c artigo 59, ambos do Código Penal.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, decido

Ante o exposto, julgo procedente pedido inicial para condenar Emerson Joaquim da Silva, nascido em 27 de dezembro de 1983, natural de São Paulo/SP, portador do RG n. 35689230, filho de Gerson Joaquim da Silva e Siria Cândida de Jesus, às penas de: i) 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ii) suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, iii) 17 (dezesete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, por incurso nos artigos 298, inciso III, e 306, caput e §1º, incisos I e II, da Lei 9.503/97.

O acusado permaneceu preso, ainda que em parte em prisão domiciliar, de 02 de

agosto a 05 de novembro de 2021, portanto, 2 meses e 5 cinco dias. Detraindo-se o tempo de prisão do total da condenação, chega-se a onze meses e vinte e cinco dias de detenção, além das demais penas não corporais. Não há, ainda, direito à progressão de regime a reconhecer, pois não atingido o patamar legal estabelecido no artigo 112, I, da LEP.

Ante o vulto da pena imposta, não cumprida em regime de máxima segregação, reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução que será provisória, caso haja recurso de qualquer das partes.

Concedo ao réu a gratuidade da justiça, já que assistido pelo convênio com a a Defensoria Pública e não restou demonstrado que possui posses incompatíveis com a declaração de pobreza. Sucumbente, condeno-o ao pagamento das custas e despesas do processo, cuja execução fica suspensa por força da gratuidade ora concedida.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito do patrono dativo, no patamar máximo da tabela.

P.I.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA